

1502507-26.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... foi injustamente acusado de praticar tráfico de drogas e porte de arma.

Não obstante a negativa do réu e os argumentos defensivos, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que ele tinha a posse das drogas e que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1502507-26.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502507-26.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KENNEDY MONTEIRO DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

KENNEDY MONTEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 c/c o art. 69, caput, do Código Penal porque no dia 8 de junho de 2022, por volta das 21h45min, na Rua Mário Bataiola, nº 501, Bloco 0-1, nesta cidade e comarca, (I) trazia consigo, para entrega e consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 145,28 gramas de cocaína, divididos em duzentos e cinquenta e três porções, e 200,96 gramas de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididos em setenta e sete porções (cf. laudos acostados aos autos), bem como (II) portava uma arma de fogo do tipo revólver, da marca "Colt", calibre 38, municiado com 5 munições íntegras e uma deflagrada, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Preso em flagrante delito, houve a conversão em prisão preventiva (fls. 53/56). 0

réu foi notificado (fls. 105) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 109/110). A denúncia foi recebida em 29/8/2022 (fls. 111/113) e o réu foi citado (fls. 146). Na audiência virtual, realizada em 4/10/2022, uma testemunha arrolada em comum foi ouvida e o réu foi interrogado (fls. 147/148 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, devem ser valoradas a grande quantidade e nocividade das drogas apreendidas, o fato de que a arma de fogo apreendida estava municiada e o envolvimento anterior do réu com atos infracionais, na época em que era adolescente. Neste contexto, inviável a caracterização do tráfico privilegiado. O regime inicial deve ser o fechado e o réu não tem direito a qualquer benesse legal (mídia).

A Defesa, em alegações finais, requereu a absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pleiteou a fixação de penas mínimas e do regime inicial aberto (fls. 152/158). É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 24/26 e 68/72), este último atestando a natureza das substâncias apreendidas (tetrahidrocannabinol e cocaína), pelas fotos da apreensão (fls. 30/31), pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 75/76) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

A testemunha Marcos Rodrigues Messias, policial militar, declarou que ele e seu colega de farda estavam realizando patrulhamento de rotina com motocicletas no local dos fatos, que é conhecido pela venda de entorpecentes. Após terem realizado uma primeira ronda, sem encontrar nada suspeito, foram avisados pelo COPOM que um indivíduo, com determinadas características, teria se escondido atrás de uma caixa d'água quando eles passavam. Munidos das características desse indivíduo, eles retornaram e avistaram o réu, que jogou uma sacola no chão e tentou se evadir. Ele foi capturado e em sua cintura havia uma pochete, contendo diversas porções de maconha e de cocaína, além de aproximadamente R\$50,00. Ele também portava um revólver calibre .38, com cinco munições intactas e uma deflagrada. Localizaram a sacola que ele havia atirado, na qual havia mais uma grande quantidade de entorpecentes. Informalmente, o réu assumiu que estava comercializando entorpecentes e realizando a segurança do ponto de venda.

O réu Kennedy Monteiro da Silva, interrogado, negou a prática do delito. Disse que depois de sair da Fundação Casa, ele estava sendo interpelado por policiais militares, os quais diziam que ele precisava entregar para eles uma arma. Na data dos fatos, quando ia com a esposa para o apartamento dela, eles novamente o abordaram e, como ele não entregou a arma, foi injustamente acusado de praticar tráfico de drogas e porte de arma.

Não obstante a negativa do réu e os argumentos defensivos, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que ele tinha a posse das drogas e que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o fato do acusado ter sido avistado em local conhecido pelo tráfico de drogas e ter tentado fugir, ao notar a presença dos policiais, jogando uma sacola no chão; b) a quantidade e natureza das drogas

apreendidas dentro da pochete que o réu usava e da sacola dispensada por ele (253 porções de cocaína e 77 porções de maconha no total); c) a forma como as drogas estavam embaladas, individualmente e prontas para venda e entrega a consumo de terceiros; d) a quantia de dinheiro apreendida com o réu, em notas e moedas, como é comum nas apreensões do comércio de drogas, cuja origem lícita não foi comprovada nos autos.

A acusação, por sua vez, encontra respaldo probatório suficiente nos autos, já que o relato do policial em Juízo e os depoimentos prestados na fase investigativa são harmônicos e coesos, descrevendo minuciosamente a diligência, desde o momento em que avistaram o réu até a apreensão dos entorpecentes.

Em relação aos testemunhos dos policiais, destaco que seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades. Aliás, não há qualquer elemento que dê suporte a eventual suspeita de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o acusado.

Já, a versão apresentada pelo acusado em Juízo restou isolada nos autos, não encontrando qualquer amparo nos demais elementos de convicção obtidos no curso da instrução processual.

Portanto, conclui-se pela prova coligida que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao delito do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão da perícia efetuada na arma de fogo ter identificado sua numeração, atestando estar aparente, e considerando, ainda, que o revólver de calibre .38 é definido como de uso permitido, entendo que a conduta imputada ao réu deve ser desclassificada para o artigo 14, caput, da citada Lei.

A materialidade do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 75/76), pelo laudo pericial (fls. 83/93), o qual atesta que a arma de fogo e as munições apreendidas em poder do réu mostravam-se aptas ao disparo, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também é certa.

Conforme declarações prestadas em Juízo e na fase investigativa pelos policiais militares que fizeram a abordagem e revista pessoal, o réu portava um revólver calibre .38, com cinco munições intactas e uma deflagrada.

Novamente, a versão do réu restou completamente isolada e dissociada do contexto probatório dos autos, não havendo que se falar em absolvição.

Não bastasse a prova oral produzida em relação ao delito, o laudo concluiu que a arma poderia ter sido eficazmente utilizada na realização de disparos (fls. 85 - item 4). Em relação aos 5 cartuchos intactos, concluiu a perícia: "Em realização de ensaios experimentais, a munição foi submetida a teste de eficácia, sendo, pois, consumida durante os exames e o estojo descartado, mostrando-se eficaz." (fls. 89/91 - item 1).

Ainda, pela prova pericial ficou comprovada que a numeração da arma que o acusado portava estava aparente, tal como atestado a fls. 85: "A arma possui a numeração 495743 impressa na armação." e demonstrado pela fotografia de fls. 88.

Em resumo, considerando que a arma de fogo apreendida estava apta a disparos,

devidamente municiada e com o número aparente, indiscutível que a condenação no artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, é medida de rigor.

Em que pesem os argumentos defensivos, não é hipótese de se reconhecer a atipicidade da conduta. Cuida-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que visa a proteger a segurança pública e a paz coletiva, não exigindo resultado naturalístico para a sua configuração, de modo que é prescindível a comprovação de risco efetivo ao bem jurídico. Ademais, cumpre ressaltar que a arma de fogo estava municiada, restando evidente a possibilidade de dano ao bem juridicamente tutelado.

Comprovadas, assim, a materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a previsão do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, entendo ser suficiente a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, o réu não ostenta Maus antecedentes (fls. 41) e não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante a ser ponderada. Verifico que incide a atenuante prevista no artigo 65, incisos I, do Código Penal, porque o réu era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (fls. 15). Contudo, não pode reduzir a pena abaixo do patamar mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Com relação à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, destaco a impossibilidade de aplicação na situação em tela. Verifico que, além da quantidade e da nocividade dos entorpecentes apreendidos, bem como da arma de fogo encontrada em seu poder, o réu ostenta antecedentes infracionais e, inclusive, cumpriu medidas socioeducativas por atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes (fls. 40). Embora tais feitos da Vara da Infância e Juventude não permitam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria ou signifiquem reincidência (artigos 59 e 64 do Código Penal c/c Súmula 444 do STJ), são dados idôneos para afastar a minorante, porquanto comprovam a dedicação às atividades delituosas desde a adolescência e a habitualidade em praticar fatos tipificados como crime. Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inaplicabilidade da redutora do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em razão da dedicação do acusado às atividades criminosas, conforme atos infracionais praticados quando adolescente. Precedentes do STJ. Substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso improvido. – Apelação nº 1500768-90.2020.8.26.0472, Rel. Reinaldo Cintra, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28/2/2021.

“(…) Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §

4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas (...)” - AgRg no HC 560.742/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 04/05/2020.

“(...) A existência de registros de atos infracionais é apta a justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicar a dedicação do réu à prática delituosa, nos moldes admitidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto (....)” - AgRg no HC 544.100/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/02/2020.

Mantenho, desta forma, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Para o crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, há a previsão abstrata de pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a previsão do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 41) e não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante a ser ponderada. Verifico que incide a atenuante prevista no artigo 65, incisos I, do Código Penal, porque o réu era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (fls. 15). Contudo, não pode reduzir a pena abaixo do patamar mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Torno, assim, final a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação para CONDENAR o réu KENNEDY MONTEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para DESCLASSIFICAR a conduta tipificada no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, CONDENANDO-O como incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Configurado o concurso material entre os delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, faz-se necessária a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade, pois foram dois os delitos perpetrados pelo réu em mais de uma ação. Assim, a soma das penas privativas de liberdade aplicadas ao réu resulta em 7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado em razão da gravidade do delito, crime equiparado a hediondo, e em virtude da expressiva quantidade de drogas apreendidas.

Além disso, verifico que, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar

o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com quantidade expressiva de entorpecentes, de nefasta repercussão social (fls. 53/56), e mantida posteriormente (fls. 111/113 - item 7), permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens, consistentes: I) no depósito judicial de fls. 73 e II) na pochete de cor preta, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20.

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o exposto permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Por fim, autorizo o encaminhamento da arma de fogo e munição apreendidas à autoridade competente, para que lhes seja dada a destinação prevista no artigo 25 da Lei n. 10.826/2003.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA